

1500909-59.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... ao crime de associação para o tráfico, não se comprovou, o que se exige de qualquer tipo de concerto necessário, a estabilidade e permanência necessárias à configuração do tipo penal.

A existência material do crime de tráfico restou demonstrada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco-SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500909-59.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500909-59.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2103685/2021 - DISE-

DEL.SEC.OSASCO, 17366748 - DISE- DEL.SEC.OSASCO, 47/21/431 - DISE- DEL.SEC.OSASCO, 2103685 - DISE- DEL.SEC.OSASCO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ALESSANDRO REZENDE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

LUIZ ALESSANDRO REZENDE, devidamente qualificados nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06, em concurso material.

Consta da denúncia que, no dia 15 de abril de 2021 e em datas anteriores, em

horário e local incertos, LUIZ ALESSANDRO REZENDE, qualificado às fls. 06/07 associou-se com os indivíduos de vulgo "Jean" e "Jorginho" para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Consta, ainda, que, no mesmo dia, por volta das 13h13min, na Rua Arístides Belini, n.º 416, Km 18, nesta cidade e comarca de Osasco, o acusado, trazia consigo, tinha em depósito e guardava drogas, para entrega ao consumo de terceiros, consistentes em 40 (quarenta) porções de cocaína, com peso líquido de 18,7 gramas, 104 (cento e quatro) porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 14,1 gramas, 92 (noventa e duas) porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 49,5 gramas, e 5 (cinco) "tijolos" de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de 4509,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão às fls. 12/13, laudo de constatação às fls. 15/18, fotografias às fls. 28/36 e laudo de exame químico-toxicológico às fls. 113/116.

Segundo o apurado, o denunciado e os indivíduos de vulgos "Jorginho" e "Jean" constituíram sociedade espúria voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, com organização e divisão de tarefas. Assim, "Jorginho", que, na estrutura da associação criminosa, trabalha para "Jean", ficou incumbido de aliciar alguém para que realizasse o armazenamento das drogas. O indivíduo de vulgo "Jorginho" então propôs ao denunciado que aceitasse armazenar os entorpecentes em sua residência em troca da quantia semanal de R\$ 600,00 (seiscentos reais), o que foi aceito. No dia 15 de abril de 2021, policiais civis, dando continuidade à operação que objetivava desestruturar o tráfico de drogas na comunidade "Rio San", receberam informações privilegiadas, de forma anônima, reportando que na Rua Arístides Belini, Km 18, na cidade de Osasco, ocorria a venda de drogas e que relevante quantidade de entorpecentes estava armazenada em uma residência. Com a finalidade de aferir tais informações, dirigiram-se ao local indicado e passaram a monitorá-lo, montando campana. Em dado momento, observaram o denunciado parado, defronte ao numeral 416, e ele demonstrava comportamento anormal, pois ficava olhando para os lados e estava inquieto. Um indivíduo se aproximou dele e lhe entregou uma cédula, tendo o denunciado entregado a tal pessoa algo que aparentava ser uma porção de droga. Diante disso, os agentes da lei se aproximaram, abordaram o increpado e o revistaram, logrando êxito em encontrar, em seu bolso, 15 (quinze) porções de maconha, bem como a quantia de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) e um celular da marca Samsung. Indagado sobre os fatos, o denunciado admitiu guardar mais entorpecentes na casa, mais especificamente embaixo da cama (no estribo). Assim, em continuação das diligências e diante da verossimilhança das informações que indicavam que havia mais drogas no interior do imóvel (n.º 416 da mesma via), os policiais civis, acompanhados do denunciado, procederam à busca no imóvel e localizaram, embaixo da cama: 5 (cinco) "tijolos" de maconha, 77 (setenta e sete) porções de maconha, 104 (cento e quatro) porções de crack e 40 (quarenta) porções de cocaína, além da quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro. Segundo o auto de exibição e apreensão às fls. 12/13, uma balança também foi apreendida. Questionado novamente, o denunciado admitiu que comercializava e armazenava os entorpecentes, os quais lhes eram entregues por uma pessoa de vulgo "Jorginho", que, por sua vez, trabalharia para uma pessoa de nome "Jean". Em seu interrogatório extrajudicial às fls. 06/07, o denunciado confessou que indivíduo de vulgo "Jorginho", que trabalharia para um tal de "Jean", propôs que guardasse os entorpecentes em sua casa, pelo que receberia a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais), semanalmente, o que acabou aceitando; complementou admitindo que também realizou a venda de algumas porções de maconha para os usuários. Pela grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associadas às circunstâncias de sua apreensão, é certo que se destinavam ao consumo de terceiros. Além do mais, tais elementos também corroboram a associação criminosa estabelecida entre o denunciado, "Jorginho" e "Jean", os quais realizavam o tráfico de drogas em uma estrutura hierárquica bem definida, sendo certo que ao denunciado era confiada

enorme quantidade de entorpecentes, alguns ainda sem estarem repartidos individualmente para a comercialização (vide os cinco "tijolos" de maconha apreendidos).

Folha de antecedentes e certidões às fls. 135/138, dando conta de que o réu é primário.

Notificado (fls. 156), o réu apresentou defesa prévia às fls. 148/151.

Às fls. 164 foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento.

O réu se encontra em gozo de liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, conforme decisão de fls. 168/171, a qual revogou a prisão preventiva anteriormente decretada. Alvará de soltura cumprido às fls. 179/181.

Deferida a quebra de sigilo dos dados telemáticos do aparelho celular apreendido (fls. 162), foi apresentado relatório de análise de dados às fls. 211/230.

Laudo de constatação às fls. 15/18 e laudo definitivo às fls. 113/116.

Laudo de constatação, descrição e fotografia da balança de precisão apreendida às fls. 244/246.

Em audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 247/248) foram ouvidas as testemunhas de acusação José Muniz de Melo Neto e Sérgio Pinto de Barros, bem como as testemunhas de defesa Juliana Menoita Alves Dias e Lecilândia Mendes Machado. Por outro lado, a Defesa desistiu da oitiva da testemunha Moisés Candido Pinheiro. Ao final, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público, primeiramente, aditou a denúncia, a fim de incluir que, entre os vulgos dos indivíduos que participam da associação criminosa, se encontra o indivíduo de vulgo Tchuchuco Chocó, conforme fls. 224 e 225, o qual conversou com o réu com o intuito de fornecer a ele drogas por atacado. Na ocasião, Sandrão mandou um áudio dizendo que pretendia assumir os negócios e afastar o Jo, reclamando que ele mistura coisas às drogas para melhorar o rendimento, fato que também denota a participação deste Jo, inicialmente confessado pelo réu como fornecedor. Requereu, em função disso, a requisição do laudo pericial do aparelho celular apreendido, com prazo de 10 dias. No mérito, requereu a procedência da ação penal, tendo em vista a existência de prova da materialidade e da autoria delitivas. Consignou que a enorme quantidade e variedade de droga apreendida, a forma de acondicionamento, o relatório referente à análise de dados do celular pertencente ao réu, aliadas às circunstâncias e condições em que se deu a prisão, demonstram indubitavelmente que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito. Requereu o reconhecimento da primariedade e da ausência de Maus Antecedentes do acusado, sustentando, no entanto, que o réu não faz jus ao benefício do art. 33, par. 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista a enorme quantidade e variabilidade de drogas apreendidas, bem como as demais circunstâncias do caso concreto, a indicar que o réu integra associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Requereu a fixação do regime inicial fechado e a decretação do perdimento dos valores obtidos por meios criminosos.

A Defesa, por sua vez, também em sede de memoriais, pugnou pela absolvição do acusado em decorrência da falta de provas, notadamente tendo em vista os depoimentos das testemunhas de defesa e o interrogatório do réu em juízo. Requereu, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o reconhecimento do direito do réu de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

i - Preliminares

Primeiramente, RECEBO o aditamento à denúncia realizado pelo Ministério Público às fls. 251/254.

Tendo em vista que não foi acrescentado fato novo à imputação, mas tão somente foi incluído o vulgo do indivíduo conhecido como Tchuchuco Chocol na descrição da suposta associação criminosa, e considerando que foi oportunizada a manifestação da Defesa, a qual, na petição de fls. 255/258, nada requereu a esse respeito, entendo desnecessária a reabertura da instrução processual.

Por outro lado, INDEFIRO o pedido ministerial de que seja requisitado junto à Delegacia de Polícia o laudo pericial do aparelho celular apreendido, uma vez que se operou a preclusão quanto a tal diligência, tendo em vista que, por ocasião da audiência de fls. 247/248, indagado o Ministério Público sobre a fase do art. 402 do CPP, nada foi requerido. Ainda, consigno que já consta das fls. 211/230 o relatório de análise de dados do aparelho celular apreendido. Para arrematar, o pedido de juntada do laudo pericial não comporta deferimento eis que tal prova é inadmissível no processo, eis que derivada de prova obtida ilicitamente, nos moldes em que será exposto adiante, quando da apreciação do *meritum causae*.

ii - Do mérito

a - Valoração probatória de autoria e materialidade

Consto, inicialmente, que as premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória que se aproxime da verdade e que vá além de qualquer dúvida razoável e possa justificar, ao final, a imposição de pena.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva, como também à comprovação da autoria e da materialidade, especialmente levando em conta a destinação da droga apreendida. Por outro lado, relativamente ao crime de associação para o tráfico, não se comprovou, o que se exige de qualquer tipo de concerto necessário, a estabilidade e permanência necessárias à configuração do tipo penal.

A existência material do crime de tráfico restou demonstrada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), imagens de fls. 27/36, laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 113/116) e laudo de objeto apreendido (fls. 244/246), afora a prova oral produzida em contraditório judicial (fls. 247/248).

Quanto à autoria, tem-se que as provas valoradas em contraditório judicial permitem com a segura e devida convicção o decreto condenatório do réu em relação ao delito de tráfico (art. 33 "caput").

Não obstante o réu tenha negado, em juízo, a prática do delito, é certo que a narrativa coesa e consistente das testemunhas policiais civis ouvidas em contraditório judicial se mostra suficiente à demonstração da autoria do crime.

Ouvida em juízo (fls. 124/127), a testemunha de acusação José Muniz de Melo Neto, policial civil, narrou que trabalha na DISE. Na data dos fatos, receberam denúncia anônima que dizia que um certo indivíduo com certas características estava comercializando drogas. A denúncia anônima foi recebida pelo telefone, pela chefia, mas não há registro. Com isso, foram ao local com a viatura descaracterizada e solicitaram que uma viatura caracterizada ficasse dando apoio. Passaram a observar a movimentação. No local havia um indivíduo branco de estatura baixa. Observaram por cerca de 8 a 10 minutos, quando saiu uma pessoa no portão; olhou para um lado, olhou para outro, desconfiado, e seguiu pela calçada. Na esquina ele atendeu um jovem. Deu dinheiro para o jovem, o que pôde ver com clareza. Entregou algo que não pôde detalhar o que era (não viu a droga). Retornou para o portão. Antes do portão, abordaram o sujeito de maneira discreta. Com ele havia 15 porções de maconha e R\$ 30,00 em notas trocadas. Falaram que o viram fazer venda de droga. Ele, diante dessa afirmação, confirmou que tinha droga; disse que estava na casa, a um ou dois metros do portão. A droga estava sob um colchão. O policial, ora testemunha Sérgio, levantou o colchão e encontrou 1 kg de maconha e 200 porções de cocaína, crack e maconha, bem como R\$ 200,00. Ele disse que estava armazenando e vendendo, bem como falou da participação de outras pessoas. Disse que trabalhava com o Jorginho ou "Jo" que tinha uma junção com a "Jean". Ele vendida droga por intermédio do whatsapp. Da análise de dados ele fazia habitualmente venda de drogas. A fim de dificultar a ação policial, ele fazia a venda pelo whatsapp. Recebia o pagamento, às vezes, até por pix. Ele recebia os valores em seu nome. Ele era conhecido por "Sandrão". Ele estava envolvido com o tráfico de drogas e mantinha relação com distribuidores de droga. Possuía o cargo de "gerente". Não sabe o valor que ele recebia, o qual não foi apurado. Estão apurando quem são as pessoas envolvidas, as quais ainda não foram identificadas. É possível que ele, o réu, tenha omitido algum vulgo ou trocado. Foi encontrada uma balança de precisão, junto com os tijolos de maconha. Foi quebrado o sigilo de dados para o aparelho móvel apreendido. Juntaram o print da transferência bancária do pix do usuário para ele. Não foi preso mais ninguém e não foi identificado mais ninguém. Não há investigação do "Jean" ou do "Jorginho"; foi o réu quem falou sobre eles. A informação nasceu de uma confissão informal. Não tiveram autorização para entrar na casa. O morador é o réu. Fizeram a abordagem, ele confirmou que tinha droga em casa.

Por sua vez, a testemunha de acusação Sérgio Pinto de Barros, policial civil, ouvida em juízo (fls. 124/127), narrou que, na ocasião dos fatos, receberam denúncia anônima feita à Chefia - o papel contendo a anotação foi jogado fora - acerca de um indivíduo que guardava droga: uma pessoa baixa, branca e careca. Foram ao local com viatura descaracterizada, estavam a aproximadamente 5 metros de lá; não há película na parte da frente do veículo, de modo que se levantassem qualquer objeto, seriam descobertos. Após 5 ou 6 minutos surgiu um sujeito no portão, meio assustado. Chegou, então, uma outra pessoa, e o indivíduo foi em direção a ela. Deu-lhe um objeto e recebeu dinheiro em troca. Antes de ele entrar no imóvel, os agentes policiais fizeram abordagem. Em revista à pessoa, foi localizada maconha, dinheiro e um celular; ele admitiu que tinha acabado de realizar uma venda. Disse que tinha mais droga dentro do quarto. Autorizou que entrassem na residência. Ele disse que estava sob o colchão a droga: 5 tijolos de maconha, 220 unidades de crack, cocaína, maconha e dinheiro; nas três bolsas tinha dinheiro, R\$ 200,00, cocaína, crack e a balança de precisão. Acreditaram que ele estaria gerenciando o local - favela Rio San. Fizeram três flagrantes no local, não na casa do réu. No momento da prisão não tinha ninguém na casa dele, ele estava sozinho, embora tenha informado que possui filhos que residem com ele. Ele disse, extrajudicialmente, que o responsável por entregar a droga era o "Jorginho" que trabalhava para o "Jean". Foi o "Jorginho" quem teria entregue a droga. Não chegaram a alguma conclusão acerca de quem seria "Jorge" ou "Jean". Tudo com base em uma confissão extrajudicial. Conduziram-no para a Delegacia. No DP houve a autorização do réu para compulsar o seu telefone; ele demonstrou arrependimento, foi tudo natural. Verificaram que havia conversas de whatsapp e venda. José Muniz compulsou o celular, o qual seria depois encaminhado para perícia. Nas conversas havia somente usuários, bem como uma

conversa com um fornecedor de nome “Choco”. Em alguns casos o pagamento era feito por meio de pix; nas conversas usavam gírias; foram localizadas duas mensagens avisando sobre a chegada da polícia. A prisão foi próxima das 13h10min, 13h15min. A investigação continua para saber quem seriam os fornecedores de droga do réu.

Inicialmente, na fase de valoração, não há porque se duvidar da versão dos policiais. A qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é porque a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com as demais provas apresentadas.

As testemunhas policiais, em essência, não discrepam em suas versões, possuem linearidade e, também, reciprocamente são coerentes e, acima de tudo, estão consentâneas com as demais provas produzidas, especialmente as materiais.

Com efeito, os policiais, em resumo, e essencialmente, afirmaram que após observar o local dos fatos, em viatura descaracterizada, visualizaram o acusado sair de sua residência e se dirigir, em via pública, até outro sujeito que lá se encontrava, realizando a troca de objetos com ele, a saber: entregou-lhe entorpecentes e recebeu dinheiro. Diante da situação de flagrância, os agentes policiais se dirigiram até o acusado e indagaram-lhe acerca do ocorrido, bem como ingressaram em sua residência, tendo sido encontradas drogas em expressiva quantidade em poder do réu, a indicar a traficância.

Pois bem. Quanto ao delito do art. 33 “caput” da Lei n. 11.343/06, a premissa fática é que o réu tinha em depósito e guardava drogas para destinação a terceiros. As provas demonstram, para além de qualquer dúvida, de fato, a conduta de guardar entorpecente sem autorização legal e regulamentar. Assim, a guarda do entorpecente na residência e a entrega para consumo a terceiro está suficientemente demonstrada pela versão dos policiais. Da mesma forma, não há dúvida quanto ao elemento subjetivo, ou seja, a consciência e vontade de guardar o entorpecente destinado a consumo de terceiro, seja pela grande quantidade, seja pela forma como estava acondicionado. Não há dúvidas, por fim, que as drogas eram voltadas ao comércio espúrio.

Quanto ao fato de as drogas terem sido apreendidas na residência do acusado, após o ingresso dos agentes policiais não munidos de mandado judicial de busca e apreensão, anoto que, mesmo sendo o crime do art. 33 da Lei de Drogas de natureza permanente, notadamente os núcleos típicos “ter em depósito” e “guardar”, fixou o Superior Tribunal de Justiça, em no voto condutor do Ministro Rogério Schietti alguns standard probatórios para validade da prova, dentre eles, não havendo consentimento expresso do morador comprovado nos autos, haver fundadas razões que justifiquem a entrada em domicílio alheio fora as hipóteses constitucionais, que devem ir além da “mera atitude suspeita” ou “fuga do indivíduo em direção a sua casa”. (Habeas Corpus n. 598.051 – SP. Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – 6ª Turma, j. 02.03.2021). Anote-se, por oportuno, que este leading case orientou a unificação do entendimento das duas turmas do Superior Tribunal de Justiça no (Habeas Corpus n. 616.584 - RS – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – 5ª Turma, j. 30.03.2021).

Contudo, no caso em tela, os policiais civis visualizaram a conduta do réu que saiu de sua residência para entregar drogas ao consumo de terceiro e, em seguida, rumar de volta ao portão de sua casa para nela reingressar, a configurar a situação de flagrante e, por conseguinte, justificar as “fundadas razões” a embasar a entrada dos policiais no local sem prévia autorização.

Quanto ao restante da prova ora produzida em juízo, além das testemunhas de

acusação policiais civis, foram ouvidas duas testemunhas de defesa e o réu foi interrogado.

A testemunha de defesa Juliana Menoita Alves Dias, ouvida em audiência judicial (fls. 124/127), narrou que não viu o momento em que o réu foi preso. Ele trabalha com transporte. Sempre cuidou dos filhos. Está sempre pronto a ajudar o próximo. Ele mora com os dois filhos. A irmã dele mora ao lado. Nunca ouviu falar que ele mexe com tráfico.

Por sua vez, a testemunha de defesa Lecilândia Mendes Machado, em sede judicial (fls. 124/127), narrou que conhece o réu há 16 anos. Não sabe de errado na vida dele. Não sei se ele mexe com tráfico. Nunca viu e nunca presenciou nada de errado. Ele mora com dois filhos. A irmã mora próximo.

Finalmente, o acusado, interrogado em juízo (fls. 124/127), declarou que faz entrega no Ceasa. Na ocasião dos fatos, chegou em torno de 10h, 10h30min. No momento saiu para fora de casa, pois entregaria um pendrive que seria para o seu filho, contendo jogo de videogame. Quando saiu foi abordado pelo policial, o qual invadiu sua casa. Ele não se identificou como polícia. Começou a lhe pressionar e coagir, pedindo dinheiro e arma. A droga não foi encontrada consigo. Se houve alguma droga, foi forjado. No momento não viu e foi levado para o quarto. Estava com a cara na parede, não podia exercer função. Nunca vendeu droga. Trabalha com hortifrúti, transporte. Não emprestou o celular para ninguém. Não tem apelido de "Sandrão". Os policiais ficaram com seu celular em torno de umas três horas dentro de casa, mexendo nele. Na Delegacia, em razão da pressão psicológica, confessou. Não leu o papel da oitiva antes de assinar. Estava sob pressão. Ficaram umas 8 ou horas rodando com ele. Frisou que não permitiu a entrada em sua casa; foi empurrado e jogado no chão. Os vizinhos não viram. Seus filhos estavam dentro de casa, estavam dormindo. Sofreu tortura psicológica e física, além do que seus filhos foram ameaçados. A ocorrência foi mais ou menos 12h00, 13h00. Não deu a senha do celular para os policiais.

Depreende-se, da análise dos depoimentos supratranscritos, que as testemunhas de defesa em nada colaboraram para a apuração da materialidade e da autoria delitivas, mas, tão somente, forneceram dados quanto à personalidade do agente e sua conduta social, a serem oportunamente valorados por ocasião da dosimetria das penas.

Por outro lado, não obstante o réu tenha negado a prática delitiva em juízo, é certo que sua narrativa restou isolada do restante do conjunto probatório, não merecendo, portanto, guarida. Anoto que as alegações do réu em juízo no sentido de que as provas teriam sido forjadas e de que ele teria sofrido tortura psicológica, não obstante se revistam de gravidade, não foram corroboradas por qualquer elemento de prova, ou sequer indiciário, a conferir-lhe verossimilhança, razão pela qual não devem ser acolhidas.

Por fim, quanto ao delito do art. 35 da Lei 11.343/06 a absolvição se impõe.

Em primeiro lugar, não há provas suficientes do concerto delito.

Com efeito, não há nos autos - porque não houve suficiente investigação por parte da autoridade policial - provas de que o concerto delitivo tenha sido estabelecido de forma estável e permanente anteriormente à prática do tráfico, até porque o crime do artigo 35 pressupõe a antecipação da tutela penal exatamente para reprimir que a união prévia de esforço de mais de duas pessoas leve à prática reiterada - ou até mesmo isolada - da traficância.

Nesse ponto, consigne-se que os únicos elementos probatórios relacionados ao envolvimento do réu com outros sujeitos com a finalidade de traficar advieram de sua confissão extrajudicial feita aos agentes policiais por ocasião de sua prisão

em flagrante, isto é, no próprio local dos fatos, prática essa que é rechaçada pela jurisprudência, já que fere os direitos e garantias do acusado, notadamente os de ser previamente informado acerca de seus direitos ("aviso de Miranda" ou Miranda warning), de ter a oportunidade de ser assistido por advogado, de permanecer calado e, por conseguinte, de não produzir provas contra si mesmo (nemo tenetur se detegere).

Em outras palavras, eventual confissão no local dos fatos não merece valoração judicial, não apenas porque não há segurança quanto às garantias constitucionais de toda e qualquer pessoa que se vê confrontada com a poder persecutório do Estado – especialmente o direito de não produzir prova contra si próprio –, mas também porque em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu negou os fatos e, ainda, afirmou não ter franqueado acesso ao conteúdo do seu aparelho celular aos policiais civis que o prenderam em flagrante. Nesse sentido: STF - AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N. 170.843/SP – REL. MIN. GILMAR MENDES – 2ª TURMA – J. 04/05/2021. Ou ainda: "Apelação. Comércio ilegal de munição. Sentença procedente. Recurso defensivo. Preliminar. Ilicitude probatória. Violação ao direito a não autoincriminação. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Desclassificação para o delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003. Aplicação da suspensão condicional do processo. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena no mínimo legal; b) aplicação do regime inicial aberto; c) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1. Preliminar. Confissão informal quanto à comercialização ilícita das munições. Violação ao direito ao silêncio. Qualquer pessoa tem o direito de permanecer em silêncio, de não declarar qualquer informação que resulte em auto-incriminação. Art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e art. 8.2.g, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Norma de eficácia imediata, direito que independe de regulamentação por norma infraconstitucional. Necessidade de advertência ao direito ao silêncio em qualquer fase da persecução penal e por qualquer agente estatal. Precedentes da Suprema Corte norteamericana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dos Tribunais Superiores Pátrios. Inadmissibilidade da prova ilícita. (...)" (TJSP - Apelação Criminal nº 1500308-45.2020.8.26.0556 – 16ª Câmara – Rel. Des. MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI – j. 1.06.2021).

Assim sendo, é certo que a prova obtida a partir da confissão extrajudicial do réu, supostamente feita aos agentes policiais civis por ocasião da prisão em flagrante, deu-se com violação às normas constitucionais e legais, sendo, por tal razão, inadmissível (art. 157, caput, do CPP).

Por conseguinte, é também inadmissível a prova derivada da ilícita, qual seja a consulta ao conteúdo do aparelho celular do réu pelos agentes policiais civis no local dos fatos sem prévia autorização judicial, na forma do parágrafo 1º do art. 157 do CPP.

Logo, sendo inadmissíveis a confissão informal do réu feita aos policiais civis e o consequente acesso ao conteúdo do seu aparelho celular, não há elementos nos autos que confirmem a imputação formulada na inicial acusatória quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, isto é, de que o réu teria se associado a outrem para o fim de traficar.

Portanto, sem outras investigações, não há como afirmar, para além de qualquer dúvida, que juntamente com pessoa não identificada, o réu teria estabelecido vínculos de estabilidade e permanência.

Portanto, não restou demonstrado, de forma segura, com provas válidas, o animus associativo. Nesse sentido sustenta Vicente Greco Filho: "Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em



que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria". (in, Tóxicos. 13 ed. Editora Saraiva, 2009, p. 184/185).

Também: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MINORANTE. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa". (STJ - AgRg no HC 661393 / SP - 6ª T - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - j. 22/06/2021 - Dje 28/06/2021).

Assim, todos os elementos do tipo penal do art. 33, "caput" da Lei n. 11.343/06 restaram demonstrados, inclusive a vontade livre e consciente de guardar a droga que seria destinada ao tráfico. Relativamente a este delito, não há qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Por outro lado, não há provas seguras do crime do art. 35, "caput", da Lei n. 11.343/06.

b - Redutor de pena

Dispõe o art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06: § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A lei estabeleceu 4 critérios para verificação do merecimento ou não do redutor de pena. Dois critérios afirmativos e dois negativos. Quanto aos afirmativos o réu deve ser primário, cuja verificação técnica se dá na forma do art. 64 do Código Penal, e ser portador de bons antecedentes (sem condenação não apta a gerar reincidência). Por outro lado, quanto aos critérios negativos, o réu não pode se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

Relativamente às atividades criminosas, depreende-se que o legislador exige uma relativa habitualidade, uma reiteração de condutas, o que deve ser extraído dos elementos probatórios disponíveis nos autos. No caso em tela, além da comprovação da prática do tráfico de drogas propriamente dito pelo réu, nas circunstâncias descritas na denúncia, não há elemento de prova que demonstre que ele se dedique, de forma pressuposta e duradoura, a atividades criminosas ligadas ao tráfico. Ao contrário, em sede policial o acusado teria afirmado que está arrependido da sua conduta, somente se envolveu com o tráfico local devido a necessidade que se encontra e as dificuldades financeiras que atravessa. Consigno, no mais, que este requisito poderia ser demonstrado caso tivesse havido maiores investigações pela autoridade judiciária, o que não ocorreu no caso em apreço.

Anoto, ainda, que a quantidade de drogas, por si só, sem outras investigações da polícia judiciária, não permite a conclusão de dedicação do réu à atividade ligada ao tráfico. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A quantidade de entorpecente isoladamente utilizada pelo Tribunal de Justiça local não é suficiente para presumir a dedicação do recorrente à atividades ligadas à traficância e, assim, negar-lhe o direito à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, mormente porque o magistrado sentenciante reconheceu sua primariedade, enfatizando que ele "não registra antecedentes, tampouco existem provas nos autos de dedicação a atividades criminosas". II - Agravo regimental a que se nega provimento." (RHC 148579 AgR,

Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018).

Por fim, a lei estabelece que não tem direito ao redutor o sujeito que integrar organização criminosa. Ora, com mais razão este critério negativo deve ser afastado. Integrar significa fazer parte ou pertencer a organização criminosa. Entretanto, a conduta de integrar exige a verificação de uma questão pressuposta, qual seja: que exista uma organização criminosa. A Lei n. 12.850/2013, no art. 1º, §1º, após muito debate doutrinário e jurisprudencial e influenciada, é verdade, pela Convenção de Palermo, estabeleceu um conceito de organização criminosa, segundo o qual: “§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

A demonstração dos requisitos do conceito legal, em primeiro lugar, exige investigação por parte das agências de persecução, o que não há no caso em tela.

Em segundo lugar, a partir da própria tipificação legal, exigem-se os seguintes requisitos objetivos para a configuração da organização criminosa: (i) a presença de 4 (quatro) ou mais pessoas; (ii) a verificação de uma estrutura ordenada; (iii) a divisão de tarefas entre os indivíduos componentes da referida estrutura, ainda que de maneira informal; (iv) a finalidade de obtenção, direta ou indiretamente, de vantagem de qualquer natureza; e (v) a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional, a fim de obter as vantagens em questão.

Assim, observa-se que a organização criminosa tem características próprias e específicas, demandando a verificação in concreto dos cinco requisitos supramencionados para a sua caracterização e consequente justificação do acréscimo de pena. Necessário, portanto, elementos mínimos que demonstrem os cinco requisitos até para que se não banalize esta figura jurídica.

É certo, portanto, que, ante a sua especialidade, a organização criminosa não se confunde com o mero concurso de pessoas ou, até mesmo, com a associação criminosa ou a associação para o tráfico. Com efeito, o concurso de pessoas se verifica com a mera concorrência de mais de uma pessoa para o mesmo crime, ensejando a punição individual de cada uma delas na medida de sua culpabilidade, nos termos do artigo 29 do Código Penal. A associação criminosa (antigo bando ou quadrilha), de seu turno, demanda, para a sua caracterização, a simples associação entre 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes, não importando as penas máximas a eles cominadas, nos moldes do artigo 288 do Código Penal. Por sua vez, o artigo 35 da Lei de Drogas (Lei 11.343/06) tipifica o crime de associação para o tráfico, exigindo, para a prática delitiva, a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, tanto não há possibilidade de integrar organização criminosa que na denúncia o Ministério fez imputação fática de associação para o tráfico, o que também não restou comprovado.

c - Da dosimetria da pena

Reconhecida a responsabilidade penal, observando o roteiro legal-dogmático do art. 68 do Código Penal, passo a aplicar a pena.

Tendo em vista a conclusão a que chegou este Magistrado na fundamentação acima consignada, no sentido de que o réu somente praticou o delito do artigo 33, caput,

da Lei de Drogas, mas não o crime associativo do art. 35 do mesmo diploma legal, passo a aplicar, tão somente, a pena pelo crime de tráfico de drogas, do art. 33 da Lei 11.343/06.

Com relação ao crime do art. 33, "caput" da Lei n. 11.342/06:

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o art. 42 da Lei 11.343/06 e o art. 59 do Código Penal, com preponderância daquele, em especial a quantidade e as espécies de drogas apreendidas ("cocaína", "maconha" e "crack"), fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, aumentando-a em 2 anos, perfazendo 7 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (STF - HC nº 91.487/RO. 1ª Turma. Rel. Min. Carmen Lúcia.j 11/09/2007, AgRec no HC - n. 181.632-PR - Rel. Min. Roberto Barroso e STJ - AgRg no HC 590.270/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020).

Na segunda fase, tendo a confissão do réu em sede policial sido utilizada, em parte, por este Magistrado para formar a sua convicção, nos termos acima expostos, não obstante tenha o réu se retratado em juízo, reduzo a sanção penal em 1/6, o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão e 417 dias-multa (Súmula 545 do STJ e STJ. 5ª Turma. HC 176405/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 23/04/2013.).

Na terceira fase, diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e presentes os pressupostos afirmativos e ausentes os negativos, diminuo a sanção em 2/3 fixando-a, em definitivo, em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 139 dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

d- Do dispositivo:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da presente ação penal e:

i- ABSOLVO o acusado o LUIZ ALESSANDRO REZENDE da acusação de ter infringido o artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

ii- CONDENO o acusado LUIZ ALESSANDRO REZENDE, qualificado nos autos, ao cumprimento de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais e ao pagamento de 139 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Caso haja necessidade do cumprimento de pena corporal (reclusão), o regime será o aberto (art. 33, parágrafo 2º, alínea "c").

f - Demais deliberações

Pela natureza da sanção o réu poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

Autorizo a destruição dos entorpecentes. Oficie-se.

Determino a destruição dos objetos apreendidos. Oficie-se.

Quanto aos valores apreendidos, primeiramente, cobre-se comprovante de depósito da

autoridade policial. Prazo de 5 dias para resposta.

No mais, não havendo requerimentos específicos até o momento, e tratando-se de quantia oriunda do tráfico de drogas, declaro o valor apreendido perdido em favor do FUNAD.

Uma vez que as receitas do Fundo Nacional Antidrogas integram a conta única do Tesouro Nacional, determino que se oficie ao Banco do Brasil para que este efetue a transferência do valor perdido, acrescido de juros legais e de mais rendimentos ao FUNAD constando as seguintes informações: código do banco 001 (Banco do Brasil), agência 1607-1, conta corrente nº 170500-8, transferências utilizando a tabela 20200-2 - UG 200246 e código identificador nº 1102460000120201. Deverá, ainda, ser encaminhado a este juízo termo de transferência.

Ainda, elabore-se o cálculo da multa e das custas processuais, acaso não se trate de réu beneficiário da Gratuidade da Justiça, e

Realize-se o abatimento dos valores atualizados, nos moldes determinados pelo art. 479 das NSCGJ.

Por fim, intime-se o condenado para recolhimento do eventual saldo devido, no prazo legal de 10 dias.

Caso transcorra o prazo em questão sem pagamento, em conformidade com o disposto no art. 480-A das NSCGJ, expeça-se certidão da sentença e dê-se vista, em seguida, ao Ministério Público para que ele próprio promova a execução da multa nos moldes do art. 51 do Código Penal.

No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Osasco, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA